

1500505-89.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... o reconhecimento do benefício do tráfico eventual, com diminuição de 2/3 da pena; a concessão dos benefícios legais; a fixação do regime prisional aberto e o direito de recorrer em liberdade (fls. 173/183).

É a síntese do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Consta da denúncia que "os policiais militares realizavam operação de combate ao tráfico de drogas na Rodovia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

5ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500505-89.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500505-89.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035208/2022 - 01º D.P. SANTOS, 22872696 - 01º D.P. SANTOS, 103/22/211 - 01º D.P. SANTOS, 2035208 - 01º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WALDEMIR DA SILVA FRANCISCO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL

Vistos.

WALDEMIR DA SILVA FRANCISCO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, bem como no artigo 33, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 7 de fevereiro de 2022, por volta das 14h20, na Rodovia Manoel Hipólito do Rego, altura do km 246, nesta cidade e Comarca de Santos, trazia consigo, tinha depósito e guardava, insumo destinado a preparação da droga, anteriormente adquirido, aproximadamente 4900 ml de cloreto de metileno/diclorometano, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi detido em flagrante delito (fls. 01).

Dispensada a Audiência de Custódia em razão da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público (fls. 43/44) e a Defesa (fls. 38/40), opinaram pela soltura, sugestão acolhida para a concessão da liberdade provisória com a fixação de algumas medidas cautelares (fls. 45/48).

Laudo de lesão corporal cautelar (fls. 72/73), laudo toxicológico (fls. 77/78). laudo da peça (fls. 93/100).

Devidamente notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 116/123). A despeito dos argumentos invocados, a denúncia foi recebida em 20 de junho de 2022 (fls. 124/125).

Na audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes debateram a causa, sustentando seus respectivos pontos de vista.

O ilustre representante do Ministério Público pediu a condenação do acusado diante da prova de autoria e materialidade dos delitos, pois trazia consigo o insumo para produção de drogas, bem como a arma de fogo de numeração suprimida. Quanto aos fatos, alega que a quantidade da droga é elevada para consumo com seu primo. Os frascos individuais tem, em média, entre 30 a 50 mililitros, o que exigiria longo prazo para consumo. Em 2021, respondeu por um ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes e, na época dos fatos, coincide com sua condenação na esfera minorista de liberdade assistida. Pela quantidade, a droga seria distribuída no varejo e teria um bom lucro, até porque demonstrou ter conhecimento no manejo das drogas. Quanto à dosimetria da pena, na ocasião dos fatos não ostentava antecedentes criminais.

A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição do acusado diante da fragilidade do conjunto probatório, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, porquanto, em sede de interrogatório, o réu esclareceu que teria adquirido a substância para uso compartilhado com seu primo, ao passo que confessou que a arma de fogo que portava era para sua defesa pessoal. Quanto à tipicidade do delito, a Defesa esclarece que o cloreto de metileno/diclorometano não houve especificação quanto à sua porcentagem de mistura na lista de substâncias entorpecentes e psicotrópicas regulamentada pela agência competente e, diante da omissão legal e a ausência prova pericial quanto à mistura realizada, pede a absolvição. Na mesma via absolutória, diante da ausência de intenção de gerar lucro, mas uso compartilhado, a conduta é, portanto, atípica. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer a desclassificação da imputação do artigo 33, § 1º, da Lei nº 11.343/2006 para o

disposto no artigo 33, § 3º, da mesma lei, ou seja, o uso compartilhado; a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento do benefício do tráfico eventual, com diminuição de 2/3 da pena; a concessão dos benefícios legais; a fixação do regime prisional aberto e o direito de recorrer em liberdade (fls. 173/183).

É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.

Consta da denúncia que "os policiais militares realizavam operação de combate ao tráfico de drogas na Rodovia Manoel Hipólito do Rego, altura do Km 246, oportunidade que pararam o coletivo da empresa Pássaro Marrom, que fazia a linha Guarujá-Caraguatatuba. Apurou-se, ainda, que os milicianos passaram abordar os passageiros que estavam no interior do coletivo, e quando chegaram na poltrona 43, avistaram o indiciado WALDEMIR, que tinha ao seu lado uma mochila e, no interior dessa mochila os policiais militares apreenderam aproximadamente 4,9 litros de cloreto de metileno/diclorometano, popularmente conhecido por "lança perfume", insumo destinado à preparação da droga que o indiciado adquiriu, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda no interior da mochila os milicianos apreenderam um revólver, calibre 32, numeração suprimida, municiado com 06 cartuchos íntegros; e um cartucho calibre 32, arma de fogo e munições que o indiciado anteriormente adquiriu e portava, também sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A quantidade de insumo destinado à preparação da droga, a forma como foi apreendido, junto com uma arma de fogo carregada, deixa evidente o intuito da mercancia.

Perante a autoridade policial o indiciado permaneceu em silêncio (fl. 06)."

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10), pelo laudo toxicológico (fls. 77/78), pelo laudo pericial realizado na peça (fls. 93/100), assim como pelas demais provas orais coligidas aos autos.

A autoria, por sua vez, é certa para sustentar um decreto condenatório.

Os policiais militares narraram a diligência com riqueza de detalhes.

David Silva Santos, Policial Militar, disse que estavam realizando bloqueio policial quando deram sinal de parada para um ônibus que faz a linha do litoral norte. Realizaram fiscalização do fundo para a frente. Na poltrona 43, o acusado foi questionado se tinha bagagem e ele apontou a mochila, onde encontraram o galão de lança perfume. Ele desembarcou. Continuaram a fiscalização, mas dentro da mochila, dentro de uma luva de boxe, havia uma arma com numeração suprimida, devidamente municiada, com outras munições soltas da sua mochila. Indagado, disse que era para a sua segurança pessoal, por ter certas desavenças naquela localidade e, com relação a droga, disse que era para consumo compartilhado com seu primo. Eram cinco litros naquele galão. Ele não indicou onde comprou, apenas que comprou na cidade do Guarujá. Ele, em momento algum, disse que comercializaria. Era fiscalização de rotina, sem qualquer suspeita. Era temporada, mês de fevereiro. A poltrona ao lado do acusado estava vazia. Não se recorda se no interior da mochila havia outros objetos do acusado ou seus documentos pessoais.

Robson da Costa Silva, Policial Militar, prestou depoimento no mesmo sentido. Disse que ele pagou cinquenta reais para consumir com seu primo. Não se recorda onde ele adquiriu a droga e nem do resultado da pesquisa acerca de seus antecedentes. Ele disse que a arma era para a sua própria segurança. Não se recorda onde ele guardava seus documentos pessoais. Ele estava sentado sozinho na poltrona e nenhum parente se apresentou na oportunidade. Acredita que o primo o aguardava no local de destino, Caraguatatuba.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, “os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Waldemir da Silva Francisco, em seu interrogatório, confessou os crimes, mas insistiu que as drogas eram destinadas ao consumo compartilhado com os demais integrantes daquela residência. Alugou uma casa com seu primo por prazo indeterminado. Ele reside com a família dele em uma casa, mas permaneceriam juntos nessa casa. Acredita que ficariam lá por uns dois meses. Era aniversário do seu primo e ele faria uma festa, quando consumiriam a droga. Ele ainda dizia que era pouca droga, mas os moradores da cidade não conhecem essas coisas por lá. Fez o lança-perfume. Adquiriu apenas dois litros e acrescentou produtos para chegar aos cinco litros. Pode ser feito de várias formas. Não gastou mais de sessenta reais. Tem uma passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de entorpecentes. Atualmente trabalha como ajudante de obra e voltou a estudar.

O acusado, em juízo, confessou que portava a droga apreendida, mas negou que seu destino fosse a entrega a consumo de terceiros.

Com relação a alegação do réu que a droga se destinava ao seu próprio consumo, importante ressaltar, por oportuno, que os delitos previstos nos artigos 33 e 28, da Lei 11343/06, restam consumados sempre que a conduta do agente se ajustar, com perfeição, a uma das figuras típicas previstas nestes dispositivos legais.

Seja no tráfico, seja no uso, a conduta do agente de portar o entorpecente restou incontroversa e consumada, restando analisar, apenas, qual o intuito deste porte: o comércio a terceiros ou o consumo próprio.

A comprovação da elementar 'consumo pessoal' exigida pelo tipo do artigo 28, da Lei 11343/06, não é circunstância de fácil constatação, devendo ser balizada pela própria situação fática.

Neste diapasão, ao tratar da antiga legislação, “A COMPROVAÇÃO DA ELEMENTAR DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 16 - USO PRÓPRIO - NEM SEMPRE É DE FÁCIL CONSTATAÇÃO, PREVENDO A PRÓPRIA LEI, EM SEU ARTIGO 37, ALGUNS CRITÉRIOS LEGAIS. ASSIM, PARA EFEITO DE CARACTERIZAÇÃO DAS CONDUTAS CRIMINOSAS PREVISTAS NA LEI 6368/76, DEVERÃO SER ANALISADOS A NATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, O LOCAL E AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, BEM COMO A CONDUTA E OS ANTECEDENTES DO AGENTE. DEVE, IGUALMENTE, SER LEVADA EM CONTA PARA EFEITO DE TIPIFICAÇÃO DO DELITO A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE”. (Legislação Penal Especial - Moraes e Smanio - ed. Atlas, pág. 122).

E ainda, “PARA CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NÃO É INDISPENSÁVEL A PROVA DO ATO DE COMÉRCIO, PODENDO SER ELE DEDUZIDO DE ELEMENTOS VARIADOS COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, A QUANTIDADE DO ENTORPECENTE, O LOCAL DA INFRAÇÃO ETC.” (TJRJ - Rel. Adolphino Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

O acusado foi preso na posse de 4900ml de lança-perfume, que não estava em embalagem usualmente destinada a facilitar o tráfico e consumo, mas integralmente acondicionado em um galão, líquido em que a perícia detectou a presença de CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO, constante na lista B1, lista de substâncias psicotrópicas, e na lista D2, lista de insumos químicos utilizados na fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos sujeitos ao controle do Ministério da

Justiça e Segurança Pública.

Uma pesquisa na internet permite concluir que realmente existem vários vídeos caseiros revelando misturas na fabricação do lança-perfume, dando suporte a versão do acusado.

Assim, a apreensão de quantidade significativa de entorpecente e que não se amolda à postura de usuários, no caso em concreto, não traz a segurança necessária para a condenação por tráfico de entorpecentes, exigindo que seja corroborado com outros elementos de prova, em especial a finalidade de obter lucro.

E, quanto ao dolo específico, inexistem provas que permitam a condenação almejada pelo Ministério Público.

Com efeito, os tipos penais que definem os delitos previstos nos artigos 33, caput, 33, § 3º e 28 da Lei 11.343/2006 são próximos e se destacam ao sopesar a forma da prisão e apreensão da droga (natureza, local, objetos apreendidos, circunstâncias, quantidade), mas, essencialmente, no elemento subjetivo do tipo, ou seja, sua efetiva destinação: consumo pessoal, consumo compartilhado com pessoas do relacionamento sem objetivo de lucro ou a traficância.

Considerando que o acusado, em todas as oportunidade em que foi ouvido, até mesmo informalmente, é firme no sentido de que estava a caminho da casa de seu primo em Caraguatatuba para comemorar seu aniversário (fl. 18), que realizou as misturas seguindo as orientações de um vídeo da internet, que seu primo e amigos achavam que não seria suficiente, que a droga estava acondicionada em um galão de cinco litros e não em pequenos frascos para garantir a fácil distribuição e o uso isolado do comprador (fl. 24), entendo que o objetivo de lucro não restou demonstrado a contento.

A versão do réu traz um oferecimento da droga eventual, a inexistência de finalidade de lucro e que as pessoas eram do seu relacionamento, seu primo e amigos, permitindo a incidência da regra prevista no artigo 33, §3º, da Lei 11.343/06.

É certo que cada frasco unitário usualmente apreendido da substância tem, em média, 50 ml, mas o consumo individual pode não encerrar neste exemplar, assim como o réu afirma que ele, seu primo e um grupo de jovens permaneceriam reunidos em uma casa alugada para comemorar o aniversário do primo.

Embora o acusado não tenha feito qualquer prova desta circunstância, a acusação também não o fez. A despeito da sua passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional equiparado ao tráfico, nada nos autos sinaliza seu intento lucrativo nesta oportunidade, dúvida que deve pender em favor do acusado.

No mesmo caminho trilha a jurisprudência: "CARACTERIZA O DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE TRAZER CONSIGO, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, MACONHA E CLORIDATRO DE COCAÍNA, EM DOSES UNITÁRIAS, DE PEQUENOS EMBRULHOS, EMBALAGEM USUAL DO VAREJO DAS DROGAS". (TJRJ - Rel. Enéas Machado Cotta, RDTJRJ 23/288).

Como se segue na ampla legalidade, na Portaria n.º 344/1998, em seu segundo item, - 2.1. - Lista B1, na forma da Resolução da Anvisa é mencionado a presença da referida droga (cloreto de metileno/diclorometano) na Lista de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e outras sob Controle Especial.

Todavia, com relação ao revólver, calibre 32 com numeração suprimida, devidamente municiado em seis cartuchos íntegros, bem como outro cartucho da respectiva arma de fogo, merece integral procedência, porquanto em desacordo com a determinação legal

e regulamentar.

A eficácia do armamento foi demonstrada pelo laudo pericial (fls. 93/100).

E: "Estando o número de série da arma de fogo raspado ou suprimido, a conduta do agente será equiparada à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, sendo irrelevante a identificação posterior pela perícia técnica da numeração, pois a intenção da lei foi punir com maior severidade aquele que, de qualquer modo, anula marca ou sinal distintivo da arma, permitindo-se sua transmissão a terceiros ilegalmente e obstaculizando/dificultando a identificação do verdadeiro proprietário do armamento" (AgRg no AgRg no AREsp 864.075/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016).

Sobre o uso permitido ou restrito, entende-se que: "HC 110792 MC / RS 'RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NUMERAÇÃO RASPADA. CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. RECURSO PROVIDO. 1. O porte de arma de fogo com numeração raspadas e adequa ao crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, pouco importando seja a arma de uso permitido, restrito ou proibido. 2. Na espécie, tendo o recorrido sido surpreendido portando arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, incabível a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. 3. Recurso especial provido a fim de restabelecer a sentença condenatória.' RESp 1047664/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 11/10/2010).

Diante do exposto, é imperioso o reconhecimento das figuras do tráfico de entorpecentes, de forma equiparada, prescrita pelo artigo 33, parágrafo terceiro, da Lei 11.343/06 e o porte ilegal de arma de fogo, prevista no artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003.

Passo a individualização das penas.

I- Do delito previsto no artigo 33, parágrafo terceiro, da Lei n.º 11.343/2006:

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do acusado que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, sua primariedade e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base no seu mínimo legal, 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, assim como a pena de advertência dos malefício do consumo de drogas por infração ao artigo 33, parágrafo terceiro, da Lei n.º 11.343/2006, e 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa por infração ao artigo 16, parágrafo primeiro, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003:.

Deixo de diminuir a pena em virtude da confissão, já que a pena, nesta fase da dosimetria, não pode transcender os limites legais, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

E, assim, na forma do artigo 69 do Código Penal, somo as penas e chego a pena de 03 (três) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu WALDEMIR DA SILVA FRANCISCO, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade 03 (três) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, calculados unitariamente, no mínimo legal, por infração aos dispostos no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, combinado com o artigo 69 do Código Penal.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, a ser indicada pelo juízo das execuções, assim como a pena de multa, que deverá ser somada a originariamente aplicada.

Concedo o réu recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado:

1. Preencha-se o boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação Criminal (art. 809 do CPP).

2. Comunique-se o deslinde do feito ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Magna Carta de 1988.

3. Proceda-se o cálculo da pena de multa, que deverá ser recolhida em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Após, intime-se o réu para o seu pagamento dentro de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 50 do CP.

Não havendo o pagamento voluntário, após a intimação para tal, extraia-se certidão, encaminhando-a à Procuradoria da Fazenda Estadual, para a adoção das medidas cabíveis, nos moldes do art. 51 do CP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 (cem) UFESP's, com base no contido no art. 4º, § 9º, alínea "b", da Lei nº. 11.608/2003, observando-se as regras pertinentes à gratuidade, caso concedida.

Determino a incineração da substância entorpecente apreendida, mediante auto circunstanciado, nos termos do art. 32, § 1º, da Lei nº. 11.343/2006 e a perda dos valores apreendidos em favor da União.

P.I.C.

Santos, 25 de outubro de 2022.

LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA